

थुनछेक, जमानत र धरौट सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र अभ्यास

डा. दिवाकर भट्ट
जिल्ला न्यायाधीश
काठमाडौं जिल्ला अदालत

प्रस्तुतीकरणको खाका

- थुनछेकको अर्थ र अवधारणा ।
- थुनछेकको उद्देश्य ।
- फौजदारी न्याय सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू
- थुनछेकका आधारहरू (तत्काल प्राप्त प्रमाण) के के हुन सक्दछन् ?
- थुनछेक सम्बन्धी सामान्य र विशेष कानूनी व्यवस्था ।
- मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को थुनछेक सम्बन्धी व्यवस्था ।
- विशेष अदालत ऐन, २०५९ र अन्य विशेष ऐनहरूमा भएको थुनछेक सम्बन्धी व्यवस्था ।
- थुनछेक सम्बन्धी साविक व्यवस्था र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था बीच समानता र भिन्नता ।
- थुनछेक सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तहरू
- थुनछेकका क्रममा आई पर्ने द्विविधाजन्य अवस्था र अनुभवहरू ।
- थुनछेक आदेश सम्बन्धी न्यायिक दृष्टिकोण ।
- छलफल
- समस्या, चुनौतीहरू र निष्कर्ष ।

थुनछेकको अर्थ

- फौजदारी मुद्दामा न्यायिक कारवाहीको (Trial) पहिलो चरण।
- अभियुक्तको अदालतमा उपस्थितिको अबस्था एकिन गर्ने कार्यविधि।
- फौजदारी मुद्दामा अदालती कारवाहीलाई निर्देशित गर्ने प्रस्थान विन्दु।
- मुद्दाको थप कारवाहीलाई एकिन गर्ने मार्गचित्र।
- कुनै पनि अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दाको न्यायिक कारवाही हुने वा धरौट वा जमानत लिई मुद्दाको कारवाही गर्ने सम्बन्धमा अपनाईने न्यायिक कारवाही।
- "First Surrender and Then Hear" को मान्यतामा आधारित न्यायिक प्रकृयाको पहिलो चरण।
- तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा अभियुक्त कसुरदार देखिएको वा कसुरदार हो भन्न विश्वसनीय वा मनासिव आधार खोजी गर्ने चरण।

थुनछेकको उद्देश्य

- समाजमा सुरक्षा प्रदान गर्ने ।
- समाजमा अपराधको नियन्त्रण गर्ने ।
- अपराध अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र बनाउने र प्रमाण लोप हुन नदिने ।
- अभियुक्तको अदालतमा उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने ।
- न्यायिक प्रक्रिया र फैसला कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने ।
- पुनः अपराध गर्न नपाउने अबस्था सृजना गर्ने ।
- अभियुक्त प्रतिको सामाजिक आक्रोशलाई कम गर्ने ।
- पिडितलाई न्याय दिलाउने ।
- साक्षी प्रमाणहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने ।
- फौजदारी न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने ।

थुनछेक पूर्वका केही प्रकृयाहरु

- अभियुक्तलाई अभियोग सुनाउनु पर्ने (१२१)
- अभियुक्तको बयान गराउने (१२२)
- बयानपूर्व कानून ब्यवसायीसँग सल्लाह लिन चाहेमा सोको मौका दिनु पर्ने (१२२)
- अभियुक्तले कसुर स्वीकार गरे मुद्दाको फैसला तत्काल गर्नु पर्ने (१२३)
- अधिकार क्षेत्र र हदम्याद सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने (५१)

अधिकार क्षेत्र र हदम्यादमा निर्णय गर्नु पर्ने दफा (५१)

- प्रतिवादीले वयान गर्दा वा प्रतिउत्तर पत्र पेश गर्दा

- अदालतको अधिकार क्षेत्र नभएको

- वादीलाई मुद्दा दायर गर्ने हकद्वैया नभएको वा

- हदम्याद नभएको भन्ने प्रश्न उठाएमा

पहिले सो प्रश्नको सम्बन्धमा निर्णय गरेर मात्र अन्य कारवाही अगाडी बढाउनु पर्ने

त्यस्तो निर्णय उपर ३० दिन भित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा उजुर गर्न सकिने

- सो प्रश्न उपर पुनः प्रश्न उठाउन नपाईने तर मुद्दाको रोहमा हुने अन्तरकालीन आदेशका हकमा यो लागु नहुने।

थुनछेक सम्बन्धी फौजदारी न्यायका मापदण्डहरू

- अभियुक्तलाई निर्दोष मान्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त, **An accused is presumed to be innocent until actually convicted.**
- ICCPR को धारा १४(२): फौजदारी अभियोग लागेका जो सुकैलाई निर्दोष अनुमान गर्नु पर्ने, निर्दोष मान्नुको अर्थ अभियुक्तलाई निर्दोषको रूपमा हेर्नु र व्यवहार गर्नु।
- ICCPR को धारा ९(३): थुनामा राखिने कुरा अपवाद हो र थुनामा राखिएकालाई मुनासिब समयभित्र सुनुवाई र छुटकारा पाउने अधिकार रहने।
- **United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)** को धारा ६(१) ले थुनामा राख्ने कार्यलाई महत्व दिन हुदैन, थुनामा राखिने कार्य अन्तिम उपाय मान्नु पर्ने मान्यता लाई स्वीकार गरेको छ। (UNO बाट १९९० मा पारित)
- नेपालको संविधान:- न्याय सम्बन्धी हक (धारा २०) कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने एवं सक्षम निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हक हुने।
- थुनछेकका आधारहरूमा मानवअधिकार सम्बन्धी अवधारणालाई नै प्रमुख रूपमा लिइने।
- नेपालको फौजदारी न्याय प्रशासनले समेत यसै अवधारणालाई स्वीकारेको छ।

थुनछेक गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

- संविधान, अन्य कानून र न्यायिक निर्णयहरू (धारा १५२(२))
- अभियोगको प्रकृति र गम्भीरता तथा अभियोगको माग दावी,
- भावि जोखिम, जस्तै: भाग्ने खतरा, प्रमाण लोप, समाज र पीडितलाई पुन्याउन सक्ने हानी आदि।
- अभियोग पुष्टि हुने प्रमाण र त्यस्ता प्रमाणहरूको **Strength/Weight**,
- अभियोग प्रमाणित भएमा हुन सक्ने सजाय तथा व्यहोर्नु पर्ने सक्ने क्षतिपूर्ति,
- अभियुक्तले प्रमाण नष्ट गर्न सक्छ वा सक्दैन र,
- थुनामा नराख्दा मुद्दाको **Settlement** मा बाधा वा अवरोध पुन्याउन सक्छ कि सक्दैन,
- अभियुक्तको उमेर, लिङ्ग, स्वास्थ्य, पारीवारिक पृष्ठभूमी र अपराध गर्दाको परिस्थिति,
- अभियुक्त तथा पीडितको आर्थिक तथा सामाजिक अबस्था,
- अभियुक्तको शारीरिक तथा मानसिक स्थिति, चरित्र तथा पटके भए नभएको अबस्था,
- तत्काल प्राप्त प्रमाणको विद्यमानता।

तत्काल प्राप्त प्रमाण के के हुन सक्दछन्?

- जाहेरी दर्खास्त वा अपराधको जानकारी वा सूचना ।
- अनुसन्धानका क्रममा खडा भएका मुचुल्काहरू ।
- प्राविधिक तथा विशेषज्ञका परीक्षण प्रतिवेदनहरू ।
- शव परीक्षण प्रतिवेदन ।
- भौतिक चीज बस्तुहरू वा दशीहरू ।
- कसुर देखे वा घटना वा वारदातको वारेमा थाहा पाउने साक्षीहरूको भनाई ।
- अभियुक्तको अनुसन्धान अधिकारी समक्षको बयान ।
- अभियुक्त र घटना बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने आधारहरू ।

अदालत समक्षको अभियुक्तको बयानलाई तत्काल प्राप्त प्रमाण मानिने हो होइन् ।

तत्काल प्राप्त प्रमाण के हुन सकदछन्?

- शुरु जिल्ला अदालतले थुनछेक प्रयोजनका लागि लास जाँच प्रकृति मुचुल्का, मेडिकल रिपोर्ट, मृतकको मृत्यु हुँदाका अवस्था देखाउने फोटो, अभियुक्तको वयान समेतलाई कर्तव्यवाला हो भन्न सकिने परिबन्द पुर्याउने प्रमाणका रुपमा लिई थुनामा राखेकामा मुद्दा पुर्पक्षका सिलसिलामा थुनछेक प्रयोजनका लागि प्रमाणमा लिन मिल्ने नै देखिन्छ।

नेत्र बहादुर समेत विरुद्ध पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत
(ने का प २०४२ नि नं २५२४ पृ. १०३०)

थुनछेक सम्बन्धमा मौजूदा कानूनी व्यवस्थाहरू

- सामान्य कानूनी व्यवस्था:
- मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ (दफा ६७-६८)
- विशेष कानूनी व्यवस्था:
- विशेष अदालत ऐन, २०५९ (दफा ७)
- बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ (दफा २४)
- लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा २१
- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ (दफा ८)
- वन ऐन, २०४९ को (दफा ६४)
- राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष ऐन, २०२९ को (दफा ३१)

थुनछेक सम्बन्धी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्था (दफा ६७ (१))

थुनाका आधारहरु

तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा

कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा

आधार र कारण खुलाउन पर्ने

थुनामा राख्ने कसूरहरु

जन्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसूर,

तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने संहिताको अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर, वा

सो कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षडयन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसूरमा मतियार भएको कसूर।

अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेराखे (दफा ६७ (१))

देहायको कुनै कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न पर्नेछ।

- (क) जन्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसूर,
- (ख) तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूर, वा
- (ग) खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित कसुरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षडयन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसूरमा मतियार भएको कसूर (Inchoate crimes)।

थुनछेकका आधार

- तत्काल प्राप्त प्रमाण भएका वा
- कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिव आधार भएमा
- विद्यमान कानून र कसुरजन्य कार्यको गम्भीरता एवं प्रमाणको विद्यमानता
- कसुरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने आधारहरू (अपराध संहिता दफा ३८ र ३९)
- न्यायिक अभ्यास।

कैदको सजाय हुने कसूरमा थुनामा राख्न सक्ने अवस्था
(विशेष व्यवस्था) (दर्फा ६७(२))

- अभियुक्तले आफूउपर लगाइएको अभियोग अदालत समक्ष स्वीकार गरेकोमा,
- एक वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्तको नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको र निजलाई थुनामा नराखेको खण्डमा निज भाग्ने र पछि पक्राउ पर्ने सम्भावना नरहेकोमा,
- अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पूर्ण बमोजिम म्यादभित्र हाजिर नभई अभियुक्त पक्राउ भई आएको र निजले उजुरी साथ अदालतमा उपस्थित हुन नआएको कुनै सन्तोषजनक कारण देखाउन नसकेकोमा,
- अभियोग लाग्नुभन्दा तीन वर्षअघिको अवधिभित्र अन्य कुनै कसूरको अभियोगमा निजले कैद सजाय पाउने ठहर भएकोमा ।

केही अपवादहरू

- दफा ६७ को उपदफा (३) बमोजिम उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि दश वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा निम्न अवस्थामा धरौट वा जमानत लिन सक्ने। दफा ६७(३)
 - बालबालिका
 - शारीरिक वा मानसिक रोग लागी अशक्त भएको
 - सात महिना भन्दा बढीको गर्भवती महिला
 - पचहत्तर वर्षमाथिको वृद्ध

अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत वा बैङ्क जमानत लिने (दफा ६८)

- दफा ६७ को अवस्था हुनेमा बाहेक अभियुक्त उपरको अभियोग प्रमाणित हुने *मनासिब आधार* भएमा अदालतले धरौट जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्ने
- बैंक जमानत *बिना शर्तको* र अदालतले तोकेको अवधिसम्म अद्यावधिक हुन सक्ने
- *अपर्याप्त भएको देखिएमा* थप धरौट, जमानत वा बैंक जमानत माग गर्न सक्ने (७०)
- माग बमोजिम धरौट, जमानत वा बैंक *जमानत नदिने* अभियुक्तलाई अदालतले थुनामा राख्ने।

धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतको रकम तोक्ने आधार (दफा ७२)

यस परिच्छेद बमोजिम लिनु पर्ने धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतको रकम तोक्दा देहायको कुरा विचार गरी मनासिब किसिमले तोक्नु पर्छ:-

- (क) कसूरको प्रकृति र गम्भीरता,
- (ख) अभियुक्त वा कसूरदारको आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक स्थिति,
- (ग) अभियुक्त वा कसूरदारको उमेर र शारीरिक स्थिति,
- (घ) निजले पहिले कुनै कसूरमा कसूरदार ठहरी सजाय पाएको वा नपाएको,
- (ङ) निजले एकै वारदातमा विभिन्न कसूर गरे वा नगरेको,
- (च) निजलाई भएको वा हुन सक्ने सजाय र निजले व्यहोर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति,
- (छ) कसूरबाट सृजित परिणाम,
- (ज) कसूरमा साबिती भए वा नभएको,
- (झ) असहाय वा अशक्त व्यक्ति वा गर्भवती वा दुधे बालबालिका भएकी महिला अभियुक्त रहेको ।

धरौट तथा जमानत निर्देशिका, २०७५

- फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७५ को दफा १९७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले धरौट तथा जमानत निर्देशिका, २०७५ तर्जुमा गरी जारी गरेको छ ।
- उक्त निर्देशिकाले के कुन अवस्थामा अदालतले कसरी अभियुक्तबाट धरौट तथा जमानत लिने सकिने भन्ने सम्बन्धमा विविध व्यवस्था गरेको छ ।

तारिखमा राख्नु पर्ने (दफा ६९)

दफा ६७ र दफा ६८ को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएपछि निजलाई तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्ने।

- मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई थुनामा राख्नु, वा धरोट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्ने। (दफा ७१)

- कसूरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि सुनुवाई गरी अदालतले थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्ने। (दफा ७१)

थुनाबाट छाड्ने

- प्रमाण बुझ्न तोकेको पहिलो पेशीको १ वर्षभित्र मुद्दा फैसला नभएमा थुनामा रहेको भए धरौटी वा जमानत लिई छाड्न सक्ने। तर जन्म कैद वा १० वर्ष वा सो भन्दा बढी सजाय हुने कसूरको अभियुक्त र पटके अभियुक्तको हकमा यो व्यवस्था लागु नहुने। (७७)

पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने (दफा ७३)

- यस परिच्छेद बमोजिम भएको थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतमा चित्त नबुझ्ने ब्यक्तिले
- एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने।
- तर जन्मकैद वा दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसूरमा भएको थुनछेकको आदेश वेरीत भएको प्रश्नमा
- एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिने।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ को उपदफा २-

- माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दश वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने मुद्दामा
- प्रतिवादीलाई पुर्पक्षको लागि तारिख, जमानत वा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश उपर
- कानूनी त्रुटी वा कार्यविधि सम्बन्धी अनियमितताको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन बाधा पुरयाएको मानिने छैन।

धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत लिँदा कागज गराउनु पर्ने (दफा ७४)

- यस परिच्छेद बमोजिम कुनै ब्यक्तिबाट धरौट लिँदा अदालतबाट तोकिएको समय र स्थानमा त्यस्तो ब्यक्ति उपस्थित नभएमा धरौट जफत हुने शर्त उल्लेख गरी कागज गराउनु पर्ने ।
- तोकिएको समयमा उपस्थित नहुने अभियुक्तले राखेको धरौट वा जमानत हुने ।

आदेश पर्चा खडा गर्नु पर्ने (७९)

- कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राख्दा थुनामा राखिएको, अभियुक्तलाई छोड्दा वा कुनै अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत लिँदा वा थपघट वा परिवर्तन गर्दा अदालतले कारण सहितको पर्चा खडा गर्नु पर्दछ।
- कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राख्दा त्यसको कानूनी आधार र कारण खुलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले अनुसूची ३२ बमोजिमको ढाँचामा थुनुवा पूर्जा दिई थुनामा राख्नु पर्नेछ। (दर्फा ८०)

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को व्यवस्था

- धरौटी वा जमानत माग्ने: तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु पर्ने नदेखिएमा निजसंग निजले हानि नोक्सानी गरेको बिगो वा गैरकानुनी रूपमा लिएको रकम र निजलाई हुन सक्ने कैद वा जरिवाना समेतलाई दृष्टिगत गरी धरौटी वा जमानत माग्ने (दफा ७(घ))
- थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने: तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिब कारण भएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने (दफा ७(ङ))

विशेष कार्यविधि लागु हुने मुद्दाहरू

वन ऐन, २०७६ (दफा ६६)

पूर्पक्ष सम्बन्धी व्यवस्था:

- एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने मुद्दाको अभियोग लागेको व्यक्ति तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएमा वा
- त्यस्तो प्रमाणबाट कसुरदार देखिन मनासिब माफिकको आधार देखिएमा
- त्यस्तो व्यक्तिलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्ने।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्य आरक्ष ऐन, २०२९ (दफा ३१)

- (१) यस ऐनको दफा २६ को उपदफा (१), (१क) र (२) अन्तर्गत कसूर हुने मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने।
- (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम जिल्ला अदालत र तोकिएको अधिकारीले यस ऐन अन्तर्गतका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने।

लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अन्तर्गतको मुद्दा

- गाँजा बाहेक लागु औषध सम्बन्धी मुद्दामा विशेष कार्यविधि अपनाउनु पर्ने (लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ को दफा २१क (२))

तर सर्वोच्च अदालतबाट जिल्ला अदालतले लागु औषध मुद्दामा सामान्य कार्यविधि अपनाई मुद्दामा थुनछेक गर्नु पर्ने रुलिङ्ग भएको छ।

- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिम अभियुक्तलाई थुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्ने :

प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि

दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को कसूरमा बाहेक

यस ऐन अन्तर्गत अन्य कसूर सम्बन्धी मुद्दामा कारबाही गर्दा

तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्तले कसूर गरेको हो भन्ने विश्वास गर्ने

मनासिव आधार भएमा अदालतले अभियुक्तलाई थुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्ने।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेको थुनछेक सम्बन्धी व्यवस्था (धारा २४)

कुनै पनि बालबालिकालाई मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राखिने छैन र निजसँग धरौटी वा जमानत मागिने छैन ।

निम्न अबस्थामा कारण खुलाई निजलाई बाल सुधार गृहमा राख्न सकिने छः

क) बालबालिकाको जीउ, ज्यान जोखिममा पर्ने वा निजबाट कुनै हानी नोक्सानी हुने वा निज भागी जाने अबस्था भएमा,

ख) तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा निज कसुरदार देखिएको वा कसुरदार हो भन्ने मनासिव आधार भएमा,

ग) माथिका अबस्था बाहेक अन्य अबस्थामा बालबालिकालाई चाहिएको अबस्थामा उपस्थित गराउने गरी निजको आमा, बाबु वा संरक्षक वा निजको हक हित संरक्षण गर्ने संस्थाको जिम्मा लगाउन बाधो पर्ने छैन ।

घ) बालबालिकालाई आमा, बाबु वा संरक्षक वा निजको हक हित संरक्षण गर्ने संस्थाको जिम्मा लगाउँदा तोकिएको शर्तको पालना नभएमा निजलाई बालसुधार गृहमा राख्न सकिनेछ ।

थुनछेक सम्बन्धी न्यायिक दृष्टिकोण

देवनन्दन महतो कोइरीको हकमा सेवक दास तत्माविरुद्ध बारा जिल्ला अदालत समेत (ने. का. प २०४९ निर्णय नं. ४५९२ पृ ६९२०)

- निवेदक उपर ज्यान सम्बन्धी महलको १७(२) नं अन्तर्गत ज्यान मार्न संयोग पारी दिएको भन्ने अभियोग लगाई मुद्दा चलाएको देखिएको तर सो संयोग पारिदिने यो यस्तो कार्य निवेदकले गरेको यो त्यस्तो तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट देखिएको भन्ने शुरूको आदेशमा उल्लेख भएको नदेखिँदा उक्त आदेश कानून अनुरूपको भन्न नमिल्ने।
- निवेदक समेतका प्रतिवादीहरूका सम्बन्धमा केवल गोश्वारा रूपमा कसरदार हो भन्ने मनासिव प्रमाण भएको हुँदा थुनामा राखी पूर्पक्ष गर्नु भन्ने आदेश भएको अ वं ११८ को मनसाय अनुकूल देखिँदैन भनी थुनामा राख्न गरेको गैरकानूनी भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको जारी भएको छ।
- त्यस्तै समान संलग्नता भएका प्रतिवादीहरूलाई समानरूपमा तारेखमा राख्न पर्नेमा निवेदकलाई थुनामा राख्न गरेको आदेश कानून संगत देखिँदैन भनी थुनाबाट मुक्त गरिएको देखिन्छ।

(थुनछेकको आदेश गर्दा प्रति व्यक्ति आधार खुलाउनु पर्ने)

मान बहादुर तामाङ विरुद्ध का.जि.अ.समेत, (ने.का.प.
२०५२, अङ्क ६, नि.नं. ६०१६)

- वारदातमा समान तथ्य र परिस्थिति भएको तथा समान संलग्नता भएका अन्य प्रतिवादीहरूलाई तारिखमा राख्ने गरी आदेश भएको,
- तर निवेदकको हकमा थनामा राख्ने गरी भएको आदेश कानून संगत नदेखिने ।

आस्ना पराजुली विरूद्ध जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण
भट्टराई, भक्तपुर जिल्ला अदालतसमेत
(नेकाप २०७४ अङ्क ५ निर्णय नं. ९८०५)

मुद्दा- बन्दीप्रत्यक्षीकरण

- अदालतमा अभियोगपत्र दायर भई थुनछेकको प्रयोजनको लागि भएको आदेशमा चित्त नबुझेको अवस्थामा वैकल्पिक उपचारको रूपमा रहेको मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. को कानूनी मार्ग अवलम्बन गरी माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिनसक्ने।
- सो अवलम्बन नगरी आदेश गर्ने न्यायाधीश एवं अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत अदालत प्रवेश गर्नु रिट विधिशास्त्रीय मान्यता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म एवं नेपालको संविधानको धारा १३३(२) एवं मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं.समेतको प्रतिकूल रहेको देखिने।

अधिवक्ता राजीव बास्तोला समेत विरुद्ध जिल्ला वन अधिकृत समेत (नेकाप २०६६, निर्णय नं. ८२०२)

विषय:- उत्प्रेषण ।

- थुनछेकलाई निषेध गर्ने हो भने कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया नै सञ्चालन गर्न सकिँदैन । त्यसरी नै शंकित आरोपित समाजमा खुल्ला रूपमा हिड्न सक्ने भै समाजले नै असुरक्षित महसूस गर्नुपर्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहन जानुका साथै कतिपय अवस्थामा त्यस्ता अभियुक्तहरूको जीउ ज्यान नै खतरामा पर्न सक्ने ।
- समाज र राष्ट्रलाई गम्भीर असर पार्ने फौजदारी कसुर गरेको आरोप लागी अदालतसमक्ष पेश गरिएका र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट सो अवस्था पुष्टि भएका अभियुक्तहरूलाई निर्दोषिताको अनुमानको आडमा छाड्दै जाने हो भने फौजदारी न्याय प्रशासनले कार्य गर्न नसक्ने ।

थुनछेक आदेशको सन्दर्भमा आउने द्विविधाहरु

- अभियोग मागदावी गोश्वरा भएकोमा थुनछेक आदेश कस्तो हुने।
- संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को समेत मागदावी लिइएको अवस्थामा के गर्ने?
- कानूनले सुबिधा प्रदान गरेका दश वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा वाहेक अभियुक्त नाबालक वा शारीरिक वा मानसिक रोग लागी अशक्त भएको वा सात महिना भन्दा बढीको गर्भवती महिला वा पचहत्तर वर्ष माथिको वृद्ध भएमा के गर्ने?
- ३ वर्ष भन्दा बढी सजाय हुने सामान्य कार्यविधि अन्तर्गतको मुद्दा छ, तर तत्काल प्राप्त मूल्याङ्कन गर्दा थुनामा राख्नु पर्ने अवस्था नदेखिएको।
- आर्थिक अपराध, ठगी, बैदेशिक रोजगार वा कम्पनी वा करारको आलोकमा कुनै अपराध भए घटेको छ भने के गर्ने?
- ३ वर्ष भन्दा कम अवधिदेखि माथि कैद हुने अपराधमा के गर्ने। जस्तै: लिखत सम्बन्धी कसुर, ठगी वा आपराधिक विश्वासघात वा ज्यान मार्ने उद्योग वा अन्यमा के गर्ने?
- अपराधको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने आधारहरुलाई के कुन रुपमा लिने।
- भावनात्मक हुने वा बस्तुगत हुने। केही भावना र संवेग न्यायिक मनको अंश भए पनि सोको प्रयोग के कति हुने।
- Media Trial
- High Profile Case
- Rape and other sexual offense (Minor and Adult)
- तत्काल प्रमाण र मनासिव आधारलाई कुन रुपमा लिने।

समस्या र चुनौतीहरू

- थुनछेक आदेशका क्रममा कानूनी प्रक्रियागत त्रुटि हुने गरेको।
- प्रतिवादीको वयानमा आवश्यक र पर्याप्त प्रश्नहरू नसोधिने गरिएको।
- थुनछेक आदेशहरूमा एकरूपताको अभाव।
- कानून व्यवसायीहरूको उपस्थिती वा अस्वभाविक उपस्थिती।
- गोश्वरा थुनछेक आदेश हुने गरेको।
- थुनछेक आदेश उपरको निवेदन दायर गरिसक्नु पर्ने समय यकिन नभएको अवस्था।
- मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको व्यवस्था केही हदसम्म स्पष्ट
- धरौट तथा जमानत निर्देशीकाको व्यवस्थालाई समेत हेर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ।
- Media Trial को अवस्थाबाट थुनछेक आदेशमा आई पर्ने चुनौती।
- चोरी मुद्दामा तीन जना प्रतिवादी भएको अवस्थामा डाँका हुने भनी परिभाषित गरिएकाले थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्ने अवस्थालाई न्यायको कसीमा कसरी हेर्ने ?

निष्कर्ष

- थुनछेक न्यायिक काम कारवाहीको महत्वपूर्ण चरण ।
- यसले समग्र न्यायिक काम कारवाहीमा दुरगामी प्रभाव पार्ने भएकोले यसमा उचित ध्यान दिनु पर्ने ।
- थुनछेकका क्रममा हुने आदेशको विविधताका कारणले पनि न्यायिक प्रकृया अनुमानयोग्य हुन नसकेको अवस्था ।
- मुद्दाको नामाकरणका कारणले मात्रै पनि थुनछेक आदेश यथोचित रूपमा हुन नसकेको ।
- अन्तमा, न्यायिक काम कारवाहीलाई त्रुटिरहित, बस्तुनिष्ठ, न्यायोचित, विवेकपरक र विश्वसनीय बनाउने क्रममा न्यायकर्मीको ध्यान जानु जरुरी छ ।

प्रश्न
जिज्ञासा
छलफल

सहभागिता र धैर्यताका लागि धन्यवाद । । ।